

1500141-20.2019.8.26.0279

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOCIMAR DAL CHIAVON

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... quarteirão do local conhecido pelo tráfico de drogas. Não me recordo, se foi no mesmo dia, ou se foram denúncias que foram se acumulando e em patrulhamento nos deparamos por ele. A informação que tinha que ele era conhecido poer tráfico de drogas, que ele abastecia o Floriza. Nós conhecemos ele por Val. Cristiano avistou ele primeiro, decidimos fazer a abordagem. Sim, ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

1ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Centro, Itararé - 18460-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500141-20.2019.8.26.0279

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3015124/2019 - 01º D.P. ITARARE, 3621358 - 01º D.P. ITARARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO CAETANO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

Aos 03 de novembro de 2022, às 14:20h, em razão da pandemia da Covid-19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Instrução e Julgamento - 1ª Vara de Itararé-SP - Processo n. 1500141-20.2019.8.26.0279 - 03/11/2022 - 14:15h", sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. JOCIMAR DAL CHIAVON, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. Thiago Gatti Fernandes, DD. Promotor de Justiça; do Defensor do réu, Dr. Luis Eduardo Fiuza, OAB 283394/SP; das testemunhas Cristiano Afonso Proença e Leonardo Kufta Júnior. O réu Osvaldo Caetano da Silva compareceu ao Edifício do Fórum local para participar da solenidade. INICIADOS OS TRABALHOS, a testemunha Cristiano Afonso Proença foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, a qual prestou depoimento e, em seguida, foi desconectada da audiência virtual. Em seguida, a testemunha Leonardo Kufta Júnior foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, a qual prestou depoimento e, em seguida, foi desconectada da audiência virtual. Após, foi oportunizado ao réu e seu Defensor conversa privativa, por meio da funcionalidade de criação de salas do Microsoft Teams. A seguir, retornando o Defensor e o réu à sala principal, procedeu-se ao

interrogatório do réu. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo e gravados através do Microsoft Teams e ficarão armazenados em nuvem através do sistema One Drive e, posteriormente, serão importados ao sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o Meritíssimo Juiz declarou encerrada a instrução, determinando-se que se passassem às alegações finais. Ato contínuo, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida, em suma, a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, por estarem presentes a materialidade delitiva e a comprovação da autoria, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. Na sequência, pela Defesa foi requerida, em suma, que sejam declaradas ilícitas as provas colhidas pelos agentes, por violação aos artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal e, no mérito, foi requerida a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. OSVALDO CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma da Lei nº 8.072/90, porque, segundo a denúncia, no dia de 10 de fevereiro de 2019, por volta das 11h14min, na Vila Tonico Adolfo, nesta cidade de Itararé, trazia consigo e transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 6 pedras grandes e farelos da droga conhecida por “crack”, cujo princípio ativo é a “cocaína”, com peso líquido de 13,42 gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06) e laudo toxicológico (fls. 30/33). O acusado foi notificado (fls. 80) e apresentou defesa prévia (fls. 86/94). A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2020 (fls. 95/96). O acusado foi citado por edital (fls. 109). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 121) e apresentou resposta escrita nos autos (fls. 125/126). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, sendo que a acusação pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu que sejam declaradas ilícitas as provas colhidas pelos agentes, por violação aos artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal e, no mérito, pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre esclarecer inexistir ilegalidade na atuação dos guardas municipais ao prender em flagrante o acusado. O fato da Constituição Federal prever, em seu artigo 144, § 8º, que a função das guardas municipais é a “proteção de seus [Municípios] bens, serviços e instalações”, não importa vedação a que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens relacionados ao delito praticado. Adotar o entendimento contrário significaria impor equivocada proibição às guardas municipais, carente de qualquer base normativa ou justificativa razoável. Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Ainda que fosse desconsiderado o enquadramento das guardas municipais na categoria de “autoridades policiais”, o que importa no dever de efetuar a prisão em flagrante, nas hipóteses cabíveis permaneceria a faculdade de os guardas realizarem flagrantes, uma vez que a norma acima expressamente determina esta faculdade a “qualquer do povo”. Isso porque, pacificou-se o entendimento de que, se a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo (art. 5º, §3º, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser feita por guarda municipal, que, nos termos do art. 4º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, “são competências específicas das guardas municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”, disposição legal esta regularmente observada, conforme se extrai dos documentos que acompanham a

exordial. Nesse sentido já decidiu tanto o Col. Superior Tribunal de Justiça este Egrégio Tribunal de Justiça como o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (STJ, Habeas Corpus nº 296.728/SP, parte da ementa, 5ª Turma, Min. Jorge Mussi, 02/09/2014). "Não se olvide, por outro lado, que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Nessa toada, sendo o guarda municipal um agente público, deve prender qualquer pessoa que se encontre em flagrante delito." (TJ/SP, Apelação nº 0005909-78.2014.8.26.0019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, 30/06/2015). Não se olvide que o artigo 3º, da Lei nº 13.022/14 expressamente previu como atribuição das guardas municipais o patrulhamento ostensivo: "São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: III - patrulhamento preventivo". No mais, não se pode igualmente olvidar que a função investigativa não é atribuição exclusiva dos órgãos da polícia judiciária, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: "(...) Finalmente, há que se salientar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o artigo 144, da Constituição Federal, não determina o monopólio da função investigativa à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa de outras autoridades (cf. HC 91613/MG, j. em 17.09.2012 e HC 84965/MG, j. 13.12.2011). Dessa forma, percebe-se que resta superada a questão da atribuição do poder de polícia aos agentes municipais, diante da expressa previsão legal para tanto." (Apelação nº 0071862-90.2014.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ricardo Sales Júnior, 05/05/2016). Assim, inexistente irregularidade a ser reconhecida, a justificar o pleiteado trancamento da ação penal, mostrando-se perfeitamente legal a prisão em flagrante do acusado pelos guardas municipais, não havendo que se falar em nulidade das provas. Assim, rejeito essa preliminar. Prosseguindo, destaco as provas indicam que é hipótese de emendatio libelli, para desclassificar o delito imputado na denúncia. Apesar da comprovação da materialidade e autoria quanto à posse das drogas, a finalidade da mercancia restou bastante controversa. Nesse sentido, confira-se a síntese da prova testemunhal: A testemunha Cristiano Afonso Proença declarou em Juízo: "Nos estávamos patrulhando com a viatura, avistamos o cidadão contra o qual a gente tinha informação de ele transportava entorpecente. Passei pro meu parceiro, retornamos, em busca pessoal foi localizada quantia de entorpecente. Foi localizada droga. Não lembro se era crack ou maconha, não tenho bem certeza. Tava na calça, na roupa dele, acho que é isso mesmo. Sim, conhecia

de vista, por questões policiais. Nós tínhamos informações que ele trabalha com reciclagem. Dinheiro não me recordo. Era uma quantidade grande, era um caroço, não lembro se era maconha ou crack, mas era quantidade razoável. A informação que a gente tinha ele levava essa droga para uma senhora que morava nas proximidades conhecida como Floriza, e ela dividia em porções pequenas para usuários. Ele tentou fugir, foi abordado alguns metros abaixo, meu parceiro o abordou. Ele estava em movimento. Estava com veículo, com motocicleta. Ele se declarou como sendo usuário de drogas. Não tenho. (...). Denúncia anônima por telefone". A testemunha Leonardo Kufta Júnior declarou em Juízo: "Não com todos os detalhes. Me recordo que recebemos denúncia de que o indivíduo conhecido como Val tava levando entorpecente do corredor da Floriza. Localizamos ele e abordamos ele e encontramos caroço, não me recordo se era maconha ou crack. Ele tava de moto. Ele falou que era pra consumo dele. Sim, já conhecia, pela prática de drogas. Foi por telefonem, anônimo. Tava no bolso da calça dele ou do short, sei que tava no bolso. Não me recordo se tava com dinheiro. Sim, é bem próximo, fica um quarteirão do local conhecido pelo tráfico de drogas. Não me recordo, se foi no mesmo dia, ou se foram denúncias que foram se acumulando e em patrulhamento nos deparamos por ele. A informação que tinha que ele

era conhecido por tráfico de drogas, que ele abastecia o Floriza. Nós conhecemos ele por Val. Cristiano avistou ele primeiro, decidimos fazer a abordagem. Sim, ele tentou, quando demos ordem de parada, ele abandonou a moto e tentou fuga. Que eu me lembro era um carão grande, não me recordo se era maconha ou crack". O acusado Osvaldo Caetano da Silva, em seu interrogatório, disse: "Verdade que tinha ido comprar droga pro meu consumo, tanto que fui pego depois com pedra e paguei serviço comunitário. Faz uns trinta anos que uso drogas. Tava num pacotinho que tinha comprado, na época foi trezentos real. Tava levando pra minha casa, que tava morando no ferro velho. Eu nunca trafiquei, era pro meu consumo só. Toda vida, pegava pra consumir. Tava com dinheiro porque entreguei reciclagem pra turma. Tenho apelido de Val, Valzinho. Nunca trafiquei droga. Fiquei porque minha ex mulher falou, ela tava com ciúme, fiquei quatro anos preso. Comprei lá na Vila Novo Horizonte, esqueci o nome do rapaz, até comentei na delegacia. (...). Comprava e vendia reciclagem, tava com trezentos e pouco reais. Tinha dado setecentos e pouquinho a carga. Usava uma semana mais ou menos. Dava média por dia uma grama e meia, duas gramas por dia. Lá que eu morava, no Corredor da Floriza, no Ferro Velho, mexia com oficina lá dentro. Ali mesmo dentro do Corredor. Tinha ido buscar droga pra consumir. Saí de lá fui lá na Novo Horizonte buscar droga. Lá eles vende muito pouquinho. Comprava na grama pra fumar. Não fiz tratamento". Em seu interrogatório judicial o acusado afirmou que a droga apreendida em seu poder era para o seu consumo. Como se vê, o acusado negou veementemente a comercialização, admitindo, no entanto, o uso de drogas, esclarecendo que aquela quantidade se destinava somente ao seu consumo pessoal. Ressalta-se que a versão do acusado não foi cabalmente infirmada pelas provas produzidas em Juízo, muito menos pelas circunstâncias do caso, eis que a quantidade da droga, por si só, não indicou a existência da traficância. Ainda que a palavra dos agentes públicos tenha grande força probatória, no caso em comento, os guardas municipais apenas abordaram o acusado trazendo consigo/transportando as referidas drogas, não havendo nenhum indício da prática do tráfico de drogas. Ou seja, nada de concreto se comprovou no sentido de que o acusado estaria efetivamente envolvido no crime de tráfico de drogas. Analisando-se as circunstâncias da apreensão, bem como os demais documentos do caderno processual, as provas orientam no sentido de que o acusado, realmente iria fazer o uso daquela droga. Assim, ante a ausência de certeza quanto à prática de tráfico de drogas, a dúvida milita em favor do acusado. Noto que, em que pese a suspeita de que o acusado possuía envolvimento com o tráfico, em razão da existência de denúncias anteriores, o certo é que a prova dos autos não demonstra com a necessária firmeza tal fato. Observo que o réu não foi flagrado na efetiva venda das drogas, os policiais não presenciaram atos suspeitos ou típicos de transação, ou mesmo não detiveram consumidores que apontassem o réu como traficante. Em síntese, os policiais não presenciaram atos de comercialização, não houve confissão formal ou informal. Enfim, a prova produzida não foi apta a demonstrar a responsabilidade do réu por tráfico, sendo de rigor a desclassificação em relação ao delito descrito na exordial, para o porte de entorpecentes, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06. Em consequência, a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida. Os fatos ocorreram em 10 de fevereiro de 2019 e a denúncia foi recebida em 25 de junho de 2020 (fls. 95/96). A infração penal em comento prescreve em dois anos (arts. 28 e 30, da Lei nº 11.343/2006). Logo, observo que a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição, eis que entre a data da interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia e esta data transcorreu prazo superior a dois anos, não havendo nos autos outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Ante o exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme descrito na denúncia, para o porte de entorpecentes para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06, e, em consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado OSVALDO CAETANO DA SILVA, com relação ao delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, em decorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigo 30 da Lei n.º 11.343/06. Faculto ao acusado a interposição de recurso em liberdade. Por fim, autorizo sejam incineradas as drogas apreendidas, providenciando a serventia as comunicações de praxe. Arbitro honorários ao advogado

nomeado no máximo previsto na tabela do convênio. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão. Comunicações e diligências necessárias. Decorrido o prazo recursal, nada mais havendo para ser deliberado, providencie-se as anotações necessárias, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe. Publicada em Audiência. Cumpra-se. Saem os presentes intimados". O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo Meritíssimo Juiz, nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. Nada mais havendo, o Meritíssimo Juiz deu por encerrada a solenidade. NADA MAIS. Eu, (Kamila Costa Luz), Escrevente Técnico Judiciário o digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotor: Defensor:

Réu: